

1502318-09.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... dos réus quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como a absolvição de ambos, quanto ao crime de associação para prática do tráfico de drogas, sustentando fragilidade probatória.

A Defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição dos réus quanto ao crime de associação para prática do tráfico de drogas, sustentando que não há investigação ou qualquer outro elemento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502318-09.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502318-09.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2279667/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 20806021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

5511/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2279667 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

5511/21/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER ANTONIO DE SOUSA JUNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

MATHEUS DE LYRA DIAS e WAGNER ANTONIO DE SOUSA JUNIOR estão sendo processados como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, após adquirirem de maneira escusa, tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico ilícito, envolvendo na atividade criminosa o adolescente KAUA WELLINGTON APARECIDO DIAS, 920,87 gramas da substância Tetrahydrocannabinol (THC), droga conhecida como "maconha", conforme auto de exibição e apreensão, laudo de

constatação e exame químico toxicológico; (2) Consta também que, em período incerto, mas até a data de 13 de outubro de 2021, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, MATHEUS DE LYRA DIAS e WAGNER ANTONIO DE SOUSA JUNIOR, este último menor de 21 anos à época dos fatos, qualificados, respectivamente, às fls. 16 e 14, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, envolvendo na atividade criminosa o adolescente KAUA WELLINGTON APARECIDO DIAS.

Notificados (fls. 94 e 146), os réus ofereceram defesa escrita (fls. 107/108 e 147/148) e a denúncia foi recebida (fls. 150/153).

Durante a instrução, inquiriram-se três testemunhas e interrogaram-se os réus. Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação dos réus quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como a absolvição de ambos, quanto ao crime de associação para prática do tráfico de drogas, sustentando fragilidade probatória.

A Defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição dos réus quanto ao crime de associação para prática do tráfico de drogas, sustentando que não há investigação ou qualquer outro elemento que comprove a prática do referido delito. Em caso de condenação, que seja aplicada pena mínima, reconhecimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelos laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 27/30 e 70/75) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria dos réus, quanto ao delito de tráfico de drogas, também é certa.

Em seu interrogatório, o réu Matheus confessou quanto ao crime de tráfico de drogas. Disse que estava fracionando as drogas quando os policiais entraram na residência. Nega que estaria associado ao réu Wagner e ao adolescente para a prática do tráfico de drogas. Já conhecia o réu Wagner e o adolescente. Foi o único dia que praticaram o tráfico de drogas. O adolescente exercia a função de "olheiro". Afirmou que preparavam e embalavam as drogas, para posterior venda.

Quando menor, teve passagens por tráfico de drogas, receptação e homicídio.

Em seu interrogatório, o réu Wagner confessou quanto ao crime de tráfico de drogas. Estavam preparando as drogas. Alegou que estavam os três dentro da residência quando os policiais chegaram. Negou estar associado ao réu Matheus e adolescente para a prática do tráfico de drogas. Afirmou que estariam fracionando as drogas, para embalagem e posterior venda. Não se recorda quem residia no local. Não sabe dizer onde as drogas seriam vendidas. Morava a um quarteirão do local dos fatos. Conhece Matheus desde criança e tinha conhecimento de suas passagens criminais quando adolescente.

O policial militar Saulo relatou que estavam em patrulhamento quando um indivíduo disse que no beco estaria ocorrendo receptação de bicicletas. Chegando ao local, o adolescente avistou a viatura e tentou se evadir para dentro da residência. Antes de entrar na residência ele dizia "molhou" - palavra utilizada para avisar da proximidade de policiais militares. O adolescente exercia a função de olheiro. Foi dada voz de parada, mas ele não obedeceu e tentou se evadir. Foi acompanhado até no interior da residência, quando surpreenderam mais dois indivíduos. Foram localizados facas, martelo e outros objetos para auxílio na embalagem das drogas. Localizaram também diversas embalagens já prontas para venda. Disse que em outras oportunidades já realizou abordagem aos réus em uma praça, mas não se recorda se foram presos. Aparentemente, a residência era utilizada para o tráfico de drogas. Estavam sentados em um cômodo, embalando as drogas. A princípio, a intenção da guarnição era adentrar ao beco para verificar a existência de bicicletas produtos de furto, mas como o adolescente tentou fuga, passaram a acompanhá-lo e lograram êxito em localizar os réus, as drogas e os apetrechos.

O policial militar Leonardo relatou que estavam em patrulhamento, quando um indivíduo disse que havia umas bicicletas produtos de furto em um beco. O local era

conhecido pelo comércio de drogas intenso. Chegando próximo da residência, o adolescente avistou a viatura e tentou se evadir. Acompanharam-no, e ao entrarem na residência, surpreenderam mais dois indivíduos. Estavam cortando e embalando drogas. A residência estava sendo utilizada exclusivamente para o tráfico. Estavam sentados no chão da sala, cortando e embalando os entorpecentes. Foram localizados facas, martelo e demais apetrechos. Havia mais de 100 embalagens prontas para comércio. Reconhece os réus como os indivíduos que estavam no local no dia dos fatos. Afirmou que conhece os réus dos meios policiais por tráfico de drogas. O adolescente foi apreendido também. Não se recorda se foi localizado dinheiro. O adolescente Kaua relatou que estava no local e a polícia chegou e os abordou. Estava na residência junto com os réus. Os três estavam fracionando as drogas. Informou que a residência era abandonada. Conhecia os réus havia pouco tempo. Disse que as drogas seriam vendidas longe da residência. Os três iriam praticar a venda. A maconha era vendida por cinco reais. Só participou da venda de drogas neste dia em que foram detidos.

Pois bem.

A confissão dos réus, quanto ao crime de tráfico de drogas, está amplamente corroborada pela prova oral produzida em juízo, sendo certa, portanto, a autoria de ambos.

Salienta-se a significativa quantidade do entorpecente encontrado em posse dos réus - que estava em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas - a maneira como estava acondicionado - além dos apetrechos apreendidos, como faca, martelo, plástico filme e balança de precisão, circunstâncias que evidenciam que a droga se destinava ao tráfico, conclusão que está de acordo, aliás, com a confissão de ambos os réus.

Induvidosa, pois, a autoria dos acusados no crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06).

A majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, está clara no caso concreto em análise, já que os policiais militares foram harmônicos e coesos ao declararem que o adolescente correu após avistar a viatura e logo em seguida foi visto na companhia dos réus, em circunstâncias que evidenciavam estarem na prática do tráfico de drogas. Ademais, como asseverado pelas testemunhas policiais, o adolescente exercia a função de "olheiro", para garantir a mercancia do entorpecente, exercendo função de vigia. Desse modo, é irrelevante que não se tenha apreendido drogas em poder do adolescente, pois, de todo modo, foi envolvido na conduta criminosa dos acusados.

Não é possível, porém, o decreto condenatório pelo crime do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06. É que não ficou provada nos autos, com certeza e clareza suficientes, a existência de associação entre os réus, de forma permanente, para a prática do tráfico com habitualidade, requisito que tem sido exigido pela jurisprudência predominante para a caracterização do delito em comento. O fato tratado nestes autos e os elementos objetivos colhidos durante a instrução a eles pertinentes revelam que os réus tinham unidade de propósitos, ou seja, praticaram o delito em coautoria, mas não ficou clara o suficiente a eventual estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Ademais, não houve investigação prévia, campanas, interceptação telefônica, ou qualquer outra diligência capaz de comprovar tais atributos da associação. Muito embora as circunstâncias indiquem a associação, em especial o fato de os acusados estarem fracionando e preparando o entorpecente para posterior comercialização, com auxílio do adolescente que atuava como "olheiro", isto é, vigiando para comunicar eventual aproximação da polícia, não é absolutamente descartável a hipótese de que os acusados estivessem realizando tal prática naquela data específica, até mesmo, eventualmente, em favor de terceiros, sem vínculo associativo de caráter permanente e estável.

Frágil demais, pois, o suporte probatório para a condenação dos réus pelo delito de associação para o tráfico, impondo-se, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Estão incursos, portanto, no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo ao cálculo das penas.

De início, deve-se ressaltar que não é correto, aliás, é absolutamente divorciado da boa técnica jurídica, o procedimento consistente em fazer incidir frações sobre a pena mínima a cada circunstância judicial desfavorável.

Primeiro, porque pena-base não se aumenta nem se diminui; se fixa, com observância dos parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do CP (art. 68 do CP).

Justamente por isso sua denominação é "pena-base", porque sobre ela incidirão eventuais frações determinadas nas duas fases subsequentes da dosimetria.

Ora, se não há ainda pena-base fixada, não há sentido cogitar-se de "aumento" ou "redução" e, conseqüentemente, na incidência de frações.

Segundo, porque, quando o intervalo entre as penas mínima e máxima é consideravelmente dilatado, como no caso em apreço (5 a 15 anos de reclusão), mesmo que todas as 8 circunstâncias judiciais fossem desfavoráveis ao réu, a aplicação de tal procedimento errôneo, ou seja, a incidência de 1/6 (fração comumente aplicada) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, jamais permitiria que a pena atingisse o máximo cominado.

Ou seja, a cominação legal de pena máxima não teria qualquer função, interpretação que obviamente deve ser descartada, por absurda, já que a lei não pode conter termos inúteis.

Feitas tais observações, quanto ao réu MATHEUS DE LYRA DIAS:

Pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na primeira fase de dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, destaca-se a expressiva quantidade de droga apreendida em poder do réu (920,87 gramas de maconha, quantidade suficiente para o fracionamento em centenas de porções individualizadas). Tal circunstância evidência, de outro lado, o elevado grau de culpabilidade do réu no delito, na medida em que revela o intenso dolo com que agiu, elevando sobremaneira o juízo de censurabilidade de sua conduta. Assim, obedecendo aos parâmetros dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, considerando a confissão do réu, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e última fase de dosimetria, aumento a pena em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, pelas razões já expostas acima, o que resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. E, por fim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), com fundamento no §4º do art. 33 da mesma lei, pois o réu é primário, não registra antecedentes criminais e não há prova de que se dedique habitualmente a atividades criminosas, nem de que integre organização criminosa. Anota-se, a propósito, que não há maiores esclarecimentos nos autos a respeito dos antecedentes infracionais do acusado, nem elementos concretos a evidenciar que, após completar 18 anos, tenha passado a dedicar-se a atividades criminosas, não se podendo presumir tal dedicação a partir de processos em andamento, sem condenação. Observo, ainda, que, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 712), não é possível a utilização da redução prevista no §4º do art. 33, se tais circunstâncias já foram consideradas na primeira fase de dosimetria, como no caso em apreço. Assim, à míngua de outros critérios balizadores no caso concreto em análise, a redução deve ser feita na fração máxima.

Resulta a pena, pois, em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Quanto ao réu WAGNER ANTONIO DE SOUSA JUNIOR:

Pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na primeira fase de dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, destaca-se a expressiva quantidade de droga apreendida em poder do réu (920,87 gramas de maconha, quantidade suficiente para o fracionamento em centenas de porções individualizadas). Tal circunstância evidência de outro lado, o elevado grau de culpabilidade do réu no delito, na medida em que revela o intenso dolo com que agiu, elevando sobremaneira o juízo de censurabilidade de sua conduta. Assim, obedecendo aos parâmetros dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis)

meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, estão presentes as atenuantes decorrentes da confissão e da idade do réu, que era menor de 21 anos na data do fato. Assim, atenuo a pena em 1/3 (um terço), o que resulta em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, observando-se que a atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira e última fase de dosimetria, aumento a pena em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, pelas razões já expostas acima, o que resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. E, por fim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), com fundamento no §4º do art. 33 da mesma lei, pois o réu é primário, não registra antecedentes criminais e não há prova de que se dedique habitualmente a atividades criminosas, nem de que integre organização criminosa. Observo, ainda, que, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 712), não é possível a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida como parâmetro para dimensionar a redução prevista no §4º do art. 33, se tais circunstâncias já foram consideradas na primeira fase de dosimetria, como no caso em apreço. Assim, à míngua de outros critérios balizadores no caso concreto em análise, a redução deve ser feita na fração máxima.

Resulta a pena, pois, em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica dos réus.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, pois, embora os réus sejam primários e a quantidade de pena aplicada admitisse, em tese, o regime mais brando, o fato concreto por eles praticado é suficientemente grave para que se imponha o regime inicial intermediário, especialmente à vista da quantidade de droga apreendida, que resultou, como visto, no agravamento da culpabilidade de ambos os réus, circunstâncias que evidenciam a absoluta insuficiência e desproporcionalidade do regime mais brando, consideradas as finalidades da pena (art. 33, §3º, do CP).

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem sua suspensão condicional (sursis), pois, como visto, a gravidade do fato concreto, e em especial o grau de culpabilidade dos réus, extraído da conduta de fracionar significativa quantidade de droga para posterior comercialização, evidenciam a insuficiência e a inadequação dos benefícios legais para se atenderem as finalidades da pena (art. 44, III, e 77, II, do CP).

Os réus poderão recorrer em liberdade, pois assim responderam ao processo e não sobrevieram razões que justificassem a decretação de suas prisões preventivas.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva para:

condenar o réu MATHEUS DE LYRA DIAS, qualificado a fls. 16, às penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

condenar o réu WAGNER ANTONIO DE SOUSA JUNIOR, qualificado a fls. 14, às penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

absolver, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, os acusados MATHEUS DE LYRA DIAS e WAGNER ANTONIO DE SOUSA JUNIOR, qualificados nos autos, da acusação de terem praticado, nas específicas circunstâncias descritas na denúncia, o crime definido no art. 35 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, façam-se as comunicações de praxe e diligencie-se pela execução das penas.

Ficam os réus dispensados do pagamento das custas por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.
Ribeirão Preto, 22 de julho de 2022.
Giovani Augusto Serra Azul Guimarães
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA